

1500065-59.2022.8.26.0612

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Comarca: Taquaritinga

Foro: Foro de Taquaritinga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/06/2022

... Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade nesta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taquaritinga

Foro de Taquaritinga

1ª Vara

Rua Duque de Caxias, 267, Taquaritinga-SP - cep 15900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500065-59.2022.8.26.0612 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500065-59.2022.8.26.0612

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2040664/2022 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 22976081 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 423/22/119 - DEL.POL.TAQUARITINGA, 2040664 - DEL.POL.SANTA ERNESTINA, 423/22/119 - DEL.POL.SANTA ERNESTINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULIO CESAR DE SOUZA VIEIRA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEOPOLDO VILELA DE ANDRADE DA SILVA COSTA

Vistos.

DEIVID GUSTAVO DOS SANTOS, JÚLIO CÉSAR DE SOUZA OLIVEIRA e GABRIEL DUTRA DA SILVA, qualificados nos autos, foram denunciados como incursos nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos Lei nº 11.343/06, porque em dia e horário não precisamente apurados, mas entre os meses de dezembro de 2021 a fevereiro de 2022, na cidade de Santa

Ernestina, Comarca de Taquaritinga, agindo de forma livre e consciente, um aderindo voluntariamente à conduta criminosa do outro, associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Consta ainda que, no dia 11 de fevereiro 2022, por volta das 19h40min, na Viela Santana, 1 Cruzamento, centro, na cidade e comarca de Taquaritinga, devidamente associados, adquiriram, transportavam e guardavam, para entrega ao consumo de terceiros, 197 (cento e noventa e sete) eppendorfs de "cocaína", 42 (quarenta e duas) pedras de "crack" e 07 (sete) papelotes de "maconha", conforme auto de exibição e apreensão (fls. 70/71), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls.72/73, 74/75 e 76/77), fotografias (fls.80/81, 83/84) e laudo pericial (fls.139/141 e 142/148), sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01/03).

Convertida em preventiva a prisão em flagrante dos acusados (fls. 138/142)

Os réus foram notificados (fls. 252, 254 e 265) e apresentaram defesa prévia (fls. 244/247).

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2022 (fls. 280/282) e, designada audiência de instrução, debates e julgamento, pelo sistema de videoconferência, foram ouvidas três testemunhas em comum e, ao final, os réus foram interrogados. Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela parcial procedência da ação penal, com a condenação dos réus pela prática do crime de tráfico de drogas. Requereu a absolvição do delito de associação ao tráfico, por insuficiência de provas.

A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu JÚLIO CESAR, por insuficiência de provas. Requereu a desclassificação com relação aos réus GABRIEL e DEIVID para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Pugnou pela absolvição dos acusados quanto ao delito de associação para o tráfico. Em caso de condenação, requereu a aplicação das penas nos patamares mínimos e o apelo em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O pedido na ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes restou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04/05), boletins de ocorrência (fls. 66/69 e 200), auto de exibição e apreensão (fls. 70/71), autos de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 72/73, 74/75, 76/77), fotografias (fls. 78/84), laudos periciais (fls. 195,197, 223/226, 227/229, 230/232 e 233/235) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria também é indubitosa.

Na fase investigativa, os réus JÚLIO CESAR DE SOUZA VIEIRA, GABRIEL DUTRA DA SILVA e DEIVID GUSTAVO DOS SANTOS optaram por permanecer em silêncio.

Interrogado em juízo, o réu JÚLIO CESAR declarou que não se associou aos demais réus para comercializar drogas. Afirmou que estava trabalhando na época dos fatos. Contou que foi para Guariba/SP visitar parentes antes de viajar para Goiás, onde iria trabalhar. Esclareceu que foi visitar uma tia e ficou no trevo da cidade para pegar carona. Anotou que conhece os demais réus. Afirmou que os policiais da cidade pegam no seu pé. Afirmou que soube das drogas quando os outros réus viram a viatura se aproximando. Disse que conhecia o carro conduzido pelo acusado GABRIEL, mas que pertence a outra pessoa. Não sabe o que GABRIEL foi fazer na cidade de Guariba/SP. Afirmou que foi na casa da tia em Guariba/SP. Asseverou que não vende droga com os réus.

Em juízo, o réu DEIVID declarou que tem 24 anos e é pintor residencial. Afirmou que os sete papelotes de maconha e os 100 pinos de cocaína foram adquiridos para uso próprio. Asseverou que comprou as drogas na cidade de Guariba/SP, tendo pago a quantia de R\$ 50,00 pelos pinos de cocaína, sendo R\$ 2,50 cada pino, e R\$ 17,50 pela maconha. Disse que usaria as drogas no final de semana. Relatou que foi até Guariba/SP com o réu GABRIEL. Falou que o carro pertence a "Carol", que tem um relacionamento com GABRIEL. Anotou que desconhece o restante das drogas. Comprou a

droga na cidade de Guariba/SP, no bairro João de Barro. Afirmou que encontrou JÚLIO CESAR do trevo de Guariba/SP, sendo que ele estava pedindo carona. Alegou que não tem envolvimento com os réus e que é usuário de drogas.

Em juízo, o réu GABRIEL declarou possui 24 anos de idade e é trabalhador rural. Anotou que já foi preso por uso de drogas e pela prática de dois furtos de moto. Afirmou que estava em Santa Ernestina desde 10 janeiro de 2022. Alegou que foi para lá porque conheceu uma moça chamada "Carol". Alegou que no dia dos fatos, após chegar do trabalho, "Carol" pediu que buscasse drogas na cidade de Guariba/SP, fornecendo-lhe a quantia de R\$ 440,00 em dinheiro. Afirmou que abasteceu o carro de "Carol" com R\$ 30,00 de combustível. Esclareceu que comprou R\$ 200,00 em crack, que custava R\$ 5,00 cada, e R\$ 210,00 de pinos de cocaína, que custava R\$ 2,50 cada. Alegou que DEIVID é colega de "Carol" e que ela pediu para que o levasse junto. Afirmou que deu carona para JÚLIO CESAR, que estava no trevo da cidade de Guariba/SP. Anotou que é conhecido dos demais réus. Alegou que JÚLIO CESAR estava na casa de uma tia e que estava esperando um ônibus. Disse que comprou a droga no Bairro João de Barro. Disse que não sabe onde DEIVID comprou droga. Afirmou que desceu em um bar e não viu onde DEIVID foi. Afirmou que DEIVID não sabia que ele também iria comprar droga. Alegou que durante a fuga ele dispensou suas drogas. Disse que não viu se DEIVID também dispensou droga. Alegou que comprou 84 pinos de cocaína. Afirmou que comprou 40 pedras de crack. Alegou que conhecia DEIVID de vista e que nunca praticou nenhum furto com ele. Alegou que foi condenado a revelia. Alegou que nunca praticou tráfico com os acusados.

Todavia, as versões dadas pelos réus se apresentam isoladas nos autos, não sendo hábeis a contrariar o conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório. A testemunha Douglas Dias Santos, policial militar, declarou que havia denúncias diárias da prática da venda de drogas pelos acusados. Esclareceu que na data dos fatos, receberam uma denúncia anônima de que os acusados teriam ido para a cidade de Guariba/SP para comprar drogas e estariam retornando à Santa Ernestina/SP. Diante da informação, deslocaram-se até a via de acesso à Rodovia Faria Lima. Disse que quando os réus, que estavam em um veículo Corsa/GM, cor verde, avistaram a viatura policial, o motorista acelerou o veículo. Afirmou que enquanto efetuavam o acompanhamento observou que os acusados arremessavam diversos objetos para fora do veículo. Dentre estes objetos, apreendeu uma pochete, cor preta, contendo uma sacola plástica, com vários flaconetes de cocaína e também uma sacolinha preta, de tecido, contendo 43 pedras de crack. Disse que os réus não pararam o veículo e o conduziam de forma perigosa. Afirmou que os réus param próximo da residência da mulher que emprestou o veículo para realizarem o transporte. Anotou que não houve resistência. Aduziu que foi localizada 07 porções de maconha no console do veículo. Explicou que marcou a referência do local onde viu os réus atirando os objetos e que retornou ao local. Afirmou que pode não ter encontrado outras drogas dispensadas pelos réus. Anotou que os acusados são conhecidos por promoverem o tráfico de drogas na cidade. Disse que não foi apreendido dinheiro. Asseverou que os réus não declararam nada, que ficaram em silêncio o tempo todo. Anotou que a droga não estava especificamente com nenhum deles e explicou que a denúncia dava conta de que eles haviam se associado para realizar a compra de uma quantidade maior de drogas.

A testemunha José Raimundo Santana de Souza declarou que sofreu um AVC e tem dificuldade em se recordar dos fatos. Lembra-se que foi abordado com duas pedras de crack e, na ocasião, foi levado à Delegacia, tendo descrito que comprou drogas de um indivíduo com cabelo "loiro", na saída de Taquaritinga/SP, próximo a um ponto de ônibus. Disse que nunca comprou drogas de DEIVID e JÚLIO CESAR, vulgos "Dê" e "Guaribinha". Alegou que forneceu R\$ 30,00 para uma mulher comprar droga, mas não sabe de quem ela adquiriu. Relatou que nunca falou que a esposa de "Dê" era a responsável pela venda das drogas. Alegou que não é usuário de drogas. Anotou que não responde a nenhum processo relativo ao uso de drogas. Afirmou que o Delegado determinou que comparece à Delegacia para tratar do fato, ocasião em que foi questionado sobre a compra de drogas junto aos réus "Dê" e "Guaribinha". Anotou que questionado, negou ter pego droga com eles. Consignou que o policial queria que ele falasse que já tinha pagado droga "com os meninos", contudo, afirmou que nunca

pegou droga com eles. Disse que o policial o ameaçou, dizendo que se não falasse bateria nele.

A testemunha Renato Cândido Soares, Delegado de Polícia, declarou que há tempos a Polícia Civil vinha recebendo informações acerca da prática do delito de tráfico pelos agentes. Afirmou que determinou a abertura de investigação para chegar as informações. Contou que recebeu denúncia de pessoa que pediu para não ser identificada de que os réus estavam reunidos próximo a um veículo Corsa Wind, de cor verde, e que estavam combinando de buscar drogas na cidade de Guariba/SP. Que de acordo com o denunciante, a quantidade de drogas seria relevante, pois serviria para abastecer a "boca de fumo" para o final de semana. Afirmou que estava em Taquaritinga/SP e que, como não tinha Policial Civil para designar para a operação, contactou o comandante da Polícia Militar de Taquaritinga, que providenciou a operação policial que culminou na prisão dos réus. Afirmou que dias após, foi apreendido um rapaz de nome Raimundo, na cidade, com drogas, que contou que tinha pegado as drogas de pessoa que estaria vendendo, mesmo após a prisão dos réus, e que estaria trabalhando para a mulher de DEIVID. Disse que, segundo Raimundo, três meses antes do ocorrido, ele havia adquirido drogas de "Dê" e de "Guaribinha" para uma mulher. Afirmou que, no dia do flagrante, foram apreendidos 197 pinos de cocaína, 40 pedras de crack e 07 porções de maconha. Consignou que, até serem detidos, os réus jogaram drogas pelo caminho. Explicou que, como não presidiu o flagrante, não soube declinar a quantidade de droga apreendida com cada acusado. Disse que não houve a degravação do celular, pois não conseguiu "quebrar".

A prova é suficiente para comprovar a autoria e, portanto, apta para ensejar a condenação dos acusados pelo delito de tráfico de drogas.

O depoimento do policial militar Douglas foi seguro ao imputar aos réus a posse de 42 (quarenta e duas) pedras de "crack" e 07 (sete) papélotes de "maconha", encontrados dentro do veículo ocupado pelos réus, além do transporte de guarda de 197 (cento e noventa e sete) eppendorfs contendo "cocaína", os quais foram dispensados pela via pelos acusados durante a perseguição policial.

Não há que se falar em valor reduzido do depoimento do policial. Nada há nos autos a apontar que tivesse algum interesse em incriminá-los falsamente e, assim o fosse, se houvesse desconsideração da palavra dos policiais em todos os processos não haveria justiça, mas sim impunidade.

Veja-se, à propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos". (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello). "Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (STJ - HC n. 449.657/SP, Min FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 14/8/2018).

No mesmo sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - RECURSO MINISTERIAL VISANDO À CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA - PROVIMENTO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS SEGUROS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. Tendo os policiais apresentado depoimentos seguros e coerentes com os demais elementos dos autos e inexistindo evidência de que aqueles tivessem qualquer motivo para incriminar o acusado falsamente, impõem-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes. Recurso provido, para condenar o apelado pelo delito do artigo 33, "caput" e §4º, da Lei nº 11.343/06. (TJSP. Apelação Criminal 1500057-52.2020.8.26.0580; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal;

Foro de Assis - 2ª Vara Criminal e da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 25/03/2021; Data de Registro: 26/03/2021) - grifei. Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo 13 porções de cocaína (2,66 gramas) - Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório - Validade. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

(TJSP. Apelação Criminal 0000581-23.2016.8.26.0594; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Duartina - Vara Única; Data do Julgamento: 01/04/2020; Data de Registro: 01/04/2020) - grifei.

Em verdade, seria um contrassenso exigir o exercício da ação inibidora da polícia para combater as infrações penais e, quando ela tem sucesso nessa empreitada, dizer que seu depoimento é inválido, suspeito, mentiroso, parcial, por que não dizer, criminoso.

Ainda, segundo o Delegado de Polícia, Dr. Renato Cândido Soares, a localização dos réus e a apreensão das drogas só foi possível em razão de denúncia anônima, realizada diretamente a ele, a qual dava conta de que os réus teriam ido até a cidade de Guariba/SP, em veículo Corsa Wind, de cor verde, buscar drogas. Diante da suspeita, o Delegado determinou que policiais militares se posicionassem na via de acesso à Rodovia Faria Lima para averiguar a veracidade dos fatos, ocasião em que observaram os réus no interior do veículo Corsa, cor verde, descrito na denúncia anônima. Em perseguição ao veículo, os policiais observaram os réus dispensando parte das drogas apreendidas.

Assim, não há como acolher a tese da defensiva, no sentido de que o acusado JÚLIO CÉSAR desconhecia a existência das drogas no interior do veículo, que estariam sendo transportadas apenas por GABRIEL e DEIVID.

Com efeito, o réu JÚLIO CÉSAR, que possui condenação por tráfico de drogas, não seria tolo de entrar em um veículo usado para transportar drogas, apenas por uma carona, como alegou em seu interrogatório. Certamente, ao visualizar as drogas no veículo, bem como o odor característico, sabedor das consequências em permanecer no carro, certamente não teria pegado carona com GABRIEL e DEIVID.

Além disso, a denúncia anônima dizia que ele e os demais acusados teriam ido até Guariba/SP para buscar drogas, o que de fato restou comprovado pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante dos réus.

Anote-se que os réus permaneceram em silêncio na fase investigativa. JÚLIO CÉSAR, mesmo preso, optou por permanecer em silêncio, não demonstrando perplexidade quanto a sua prisão.

Portanto, não há dúvida quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.

Registre-se que a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da forma como estavam embaladas autoriza a considerar que as substâncias entorpecentes eram destinadas ao consumo de terceiros, sendo tal preceito expresso na Lei nº

11.343/06.

Cumpra anotar, que em razão do crime de tráfico de drogas constituir atividade clandestina, não é necessário, para a sua caracterização, o flagrante da comercialização das substâncias ilícitas para que se conclua pela autoria do crime em tela, sendo suficiente para tanto a análise das circunstâncias e indícios que conduzem a incriminação, todos a respaldar a convicção pela autoria dos acusados no crime de tráfico de drogas.

À propósito, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, CAPUT, E § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DOLO ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. 1. Para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente. 2. O tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 não faz

nenhuma exigência no sentido de que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, seja necessária a demonstração de dolo específico, notadamente quanto ao fim de comercialização do entorpecente. 3. Recurso especial provido, para cassar o acórdão recorrido e, consequentemente, restabelecer a sentença condenatória. (STJ - REsp 1361484/MG Rel. Min. Rogério Schietti Cruz Sexta Turma j. 10/06/2014).

No mesmo sentido:

Tráfico de Entorpecentes - Art. 33, Lei 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. Pena base reduzida.

Substituição da pena. Incabível - Requisitos dos benefícios não foram satisfeitos. Regime mantido. Recurso parcialmente provido. (TJSP. Apelação Criminal 0016290-94.2017.8.26.0196; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franca - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/06/2019; Data de Registro: 13/06/2019) - grifei.

Diante desse cenário, não há como recepcionar a alegação de insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico de entorpecentes imputado aos acusados. Isso porque, os relatos apresentados pelo policial militar Douglas, pelo Delegado de Polícia Renato, e a prova pericial coligida, constituem provas firmes e robustas, mais que suficientes a reforçar a convicção de que eles realmente adquiriram, transportavam e guardavam drogas no local em que foram detidos em flagrante, na ocasião.

Ademais, é cediço que a condição de usuário não afasta, necessariamente, a de traficante, pois, na maioria das vezes, os usuários se valem do comércio ilícito de entorpecentes para sustentar o próprio vício, de modo que uma conduta não exclui a outra.

O uso de entorpecente é a porta de entrada para a atividade de traficância. Assim, incabível o pleito desclassificatório, pois as drogas que possuíam não eram destinadas ao uso. Neste sentido: "A condenação penal pelo crime de tráfico não é vedada pelo fato de ser também o agente um usuário da droga. Não descaracteriza o delito de tráfico de substância entorpecente o fato de a Polícia haver apreendido pequena quantidade do tóxico em poder do réu" (STF 1ª T. HC n. 74.420-6/RJ Rel. Min. Celso de Mello DJU de 19.12.96, p. 51.768).

Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação, mostrando-se a prova colhida absolutamente suficiente para a condenação.

De outro giro, não restou devidamente comprovado nos autos a prática do delito de associação para o tráfico pelos acusados.

De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores, a configuração do tipo associação para o tráfico, exige estabilidade e permanência na associação criminosa. Dessa forma, deve haver ânimo associativo permanente e duradouro.

À propósito:

"HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública - capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado -, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré." (HC 124164, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014).

"A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento no sentido de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 3. No caso, as instâncias ordinárias, ao concluírem pela condenação dos pacientes em relação ao crime previsto no artigo 35 da Lei n. 11.343/2006, em momento algum fizeram referência ao vínculo associativo estável e permanente porventura existente entre eles, de maneira que, constatada a mera associação eventual entre os acusados para a prática do tráfico de drogas, devem ser absolvidos em relação ao delito de associação para o narcotráfico" (STJ – HC 108.359/MS, Rel. Min. Rogério Schietti, 6ª Turma, julgado em 26/11/2013, DJe 12/12/2013);

Na hipótese, apesar dos depoimentos prestados pelo Policial Militar Douglas e pelo Delegado de Polícia Renato, das denúncias anônimas acerca da prática delitiva pelo grupo, não foram produzidas outras provas suficientes a comprovar o vínculo associativo estável e permanente existente entre os réus.

Destaque-se que a testemunha José Raimundo negou que tenha adquirido drogas de "Dê" e "Guaribinha" em data anterior e/ou em data posterior à prisão dos réus em flagrante.

Neste contexto, nenhuma prova foi produzida, não restando suficientemente configurado o animus associativo entre os réus, revelado pelo critério de estabilidade, permanência e habitualidade.

Neste tear, considero que os elementos de convicção carreados aos autos são insuficientes para atribuir aos acusados a responsabilidade criminal pela prática do delito.

Assim, não havendo essa certeza, a absolvição quanto a imputação pelo delito previsto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06 é, portanto, a medida que melhor se amolda ao caso.

Portanto, caracterizado o crime de tráfico de drogas, a condenação é medida que se impõe.

Passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação das penas.

Respeitado o sistema trifásico, a pena base do réu GABRIEL será majorada em 1/4, tendo em vista os maus antecedentes (Proc. 1500271-44.2020.8.26.0612 – fls. 317) e em razão da diversidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, já que a cocaína possui efeitos devastadores, fato que também acarreta a elevação em 1/6 das penas base dos réus JÚLIO CÉSAR e DEIVID.

Com efeito, quando o legislador determinou, no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, que o juiz, na fixação das penas, considere com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância, quis dizer que, quem trafica cocaína deve ser punido mais severamente do que quem trafica outras drogas menos vulnerantes, como, por exemplo, apenas a maconha.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO – Tráfico de entorpecentes – Recurso da defesa – Absolvição – Improcedência – Materialidade e autoria demonstradas – Acusado surpreendido com 14 pinos de cocaína, com peso líquido total de 19,41g – Firmes e coerentes os depoimentos dos policiais militares – Intuito mercantil demonstrado – Condenação de rigor – Dosimetria – Pena-base fixada 1/6 acima do mínimo legal – Natureza do entorpecente apreendido que justifica o aumento – Artigo 42 da Lei nº 11.343/06 – Reprimenda agravada em 1/6 pela reincidência – Redutor do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 e Substituição penal – Inaplicabilidade – Requisitos legais não preenchidos – Regime inicial fechado mantido, porque adequado à gravidade concreta da conduta praticada – Recurso não provido (TJSP. Apelação nº 0001327-39.2018.8.26.0619. Relator(a): Salles Abreu. Comarca: Taquaritinga. Órgão julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal. Data do julgamento: 17/12/2018. Data de publicação: 15/01/2019). Negritei.

Ainda, a esse respeito:

"O juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006". (AgRg no HC 631774 / SE AGRADO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2020/0327617-0. Relator(a) Ministro FELIX

FISCHER (1109) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/03/2021 Data da Publicação/Fonte DJe 29/03/2021) - grifei.

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA.

NATUREZA NOCIVA DAS DROGAS APREENDIDAS (CRACK E COCAÍNA). ART. 42 DA LEI N.

11.343/06. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos crimes de tráfico de drogas, o Juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal - CP, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. No caso, a natureza das drogas apreendidas (crack e cocaína) justifica a majoração da pena-base, em relação à Debora, bem ainda a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em seu patamar mínimo, para o réu Geraldo. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. Processo" (AgRg no HC 476995 / SC AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0289466-0 Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 23/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019) - grifei.

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC 687055624 - Rel. Des. Jorge Alberto de Moraes Lacerda, v. un. 29.12.1987).

Penas base, portanto, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão para os réus JÚLIO CÉSAR e DEIVID e em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão para o réu GABRIEL.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes a computar. Incide a agravante da reincidência para todos os réus, conforme se verifica das certidões de antecedentes acostadas às fls. 271/274, 275/277 e 317/320 dos autos (JÚLIO CESAR - Proc. ° 1500457-80.2019.8.26.0619 - fls. 273; DEIVID - Proc. nº 1500215-24.2019.8.26.0619 - fls. 275; GABRIEL - Proc. nº 1500215-24.2019.8.26.0619 e 1500407-88.2018.8.26.0619 - fls. 317/320), acarretando a majoração das penas em 1/6. Penas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para os réus JÚLIO CESAR e DEIVID e em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para o réu GABRIEL.

Na terceira fase, não há modificadores, fato pelo qual torno as penas em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão para os réus JULIO CÉSAR e DEIVID e em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, para o réu GABRIEL, definitivas.

As penas pecuniárias, utilizados os mesmos critérios das privativas de liberdade, são fixadas em 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para os réus JULIO e DEIVID e em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa para o réu GABRIEL, no valor unitário mínimo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, fixo o fechado para todos os acusados, diante da reincidência dos réus, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, e por ser o único compatível com a natureza do delito, equiparado a hediondo.

Não é demais consignar que as nefastas circunstâncias e consequências que o crime de tráfico de entorpecentes causam à sociedade conclamam a fixação do regime mais gravoso, a fim de que se retire os infratores do convívio social, evitando que eles continuem a exercer tais atividades ilícitas, viciando pessoas e destruindo famílias. Nesse sentido os recentes julgados do E. Tribunal de Justiça deste Estado: Apelação nº 0001994-15.2011.8.26.0443, 4ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luis Soares de Mello, j. 26.06.12, e Apelação nº 0011197-28.2006.8.26.0038, 9ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Roberto Midolla, j. 28.06.12.

Além disto, o tráfico suporta o vício. E para o viciado obter recursos para obter a droga muitas vezes comete outros delitos, em especial, delitos patrimoniais. Assim, indiretamente, o tráfico fomenta toda uma gama de criminalidade. Diversos crimes orbitam o tráfico de entorpecentes.

Na atual sociedade nesta Comarca, o tráfico é delito de extrema relevância que demanda combate diuturno das autoridades policiais, judiciárias e do Ministério Público.



Assim, diante das graves consequências sociais, inviável imputar aos traficantes regime de pena menos rigoroso do que o fechado.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para:

A) CONDENAR os réus DEIVID GUSTAVO DOS SANTOS e JÚLIO CÉSAR DE SOUZA OLIVEIRA, qualificados nos autos, às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no mínimo legal, para cada um dos réus, por incursos no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06;

B) CONDENAR o réu GABRIEL DUTRA DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal, por incurso no artigo 33, caput da Lei n.º 11.343/06;

C) ABSOLVER os réus DEIVID GUSTAVO DOS SANTOS, JÚLIO CÉSAR DE SOUZA OLIVEIRA e GABRIEL DUTRA DA SILVA, qualificados nos autos, da imputação que lhes foi feita por incurso nos artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de dar aplicação ao disposto no art. 2º, §2º, da Lei nº 12.736/12 por entendê-lo inconstitucional.

A uma, porque fere o princípio do juiz natural, na medida em que cabe à Vara de Execução Criminal apreciar a progressão de regime prisional, não possuindo esse juízo, ademais, os elementos necessários para avaliar se o tempo de prisão cumprido até aqui diz respeito a esse ou a outro processo criminal.

A duas, porque viola o princípio da isonomia, na medida em que trata desigualmente réus que praticaram delitos idênticos, quando um deles ficou preso cautelarmente por mais tempo do que o outro.

A três, porque ofende o princípio do livre convencimento motivado do magistrado na sentença, a quem cabe apreciar a justa aplicação da pena.

Nego aos acusados o direito de recorrer em liberdade, porque, se eles permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, sejam beneficiados pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 138/142.

Recomende(m)-se o(s) réu(s) na(s) prisão(ões) em que se encontra(m).

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei nº 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder dos réus em favor da União (fls. 70/71).

Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Transitada em julgado esta sentença: a) destruam-se as amostras de droga guardadas para contraprova (art. 72 da Lei de Drogas); b) expeça-se/adite-se e encaminhe-se guia de recolhimento definitiva; c) elabore-se cálculo de multa e intimem-se os réus para o pagamento; d) oficie-se ao Instituto de Identificação (IIRGD); e) oficie-se ao TRE/SP, para os fins do art. 15, III, da CF;

Condeno os sentenciados ao pagamento das custas, no valor equivalente a 100UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, observada a gratuidade, que ora defiro.

P.I.C.

Taquaritinga, 18 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA